

SENTENCIA NUMERO: 12. VILLA M., 04/03/2024. **Y VISTOS**: estos autos caratulados "**V., G. A. Y OTRO – TUTELA, Expte.**" del que resulta:

a) La demanda. Comparecen G. A. V., DNI y A. V., DNI, con el patrocinio de la Dra. S.T., MP, y refieren que son hijas de N. H. V. y M. I. P., ambos fallecidos, y que al fallecimiento de su hermana M.na S. V., sus padres asumieron la responsabilidad del cuidado de las hijas de la causante, y fueron designados tutores de V. V., DNI, nacida el 21 de diciembre de 2005; y J. T. V., DNI, nacida 07 de marzo de 2010. En consecuencia, a raíz del fallecimiento de sus padres, peticionan la tutela de sus sobrinas V. V. y J. T. V. Mencionan que, desde el fallecimiento de su madre, las menores por decisión propia y con su acuerdo, viven en casa de G. A. V., quién ha asumido el cuidado personal y la responsabilidad parental de hecho. Afirman que G. A. V., reside en zona rural al norte de Villa María hacia Tío Pujio, donde es empleado su conviviente, R. E. S.; y que de esa en unión convivencial nacieron dos hijos de 9 y 3 años de edad. Aducen que, habiendo cesado la tutela por fallecimiento de los tutores, es su intención, que se le otorgue la tutela dativa de ambas niñas a G. A. V.. Destacan que, al cuidado de G. A., las niñas crecen conformes, en un ámbito familiar, reciben afecto, contención, alimentos, diversión, tienen buena conducta. Durante el período escolar la mayor reside en Cintra, concurre a la Escuela Secundaria en el último año; y los fines de semana reside en casa de G.; y la menor concurre al Secundario PROA en Villa María. Mencionan que, en esos colegios, ambas comparecientes están designadas como sus representantes legales. Manifiestan que ello es así, a partir de que el padre de J. T. V., el señor C. E. T. DNI, domiciliado en M. de Villa María, les diera la guardia provisoria en noviembre del año 2022. Adjunta documento, celebrado ante Juzgado de Paz. Mencionan que ante el Juzgado de 1a Instancia Civ. Com. y Flia. de 4ª Nominación, Secretaria 8, han iniciado la declaratoria de herederos de sus padres, autos "V., N. H. - P., M. I. – DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.), por lo que, las menores serán declaradas herederas por representación de su hermana prefallecida y consecuentemente heredarán bienes de esta sucesión.

b) Dada a la demanda el trámite correspondiente, con fecha 16/02/2023 comparece a estar a derecho C. E. T., DNI, y expresa su consentimiento para delegar la responsabilidad parental de su hija J. T. V., a su tía G. A. V., en los términos que dispone el art. 643 CCyC. Refiere que la relación con toda la familia V., es muy buena, y que oportunamente delegó la titularidad a los abuelos de J., quienes lamentablemente fallecieron al poco tiempo. Que desde ese momento J. se trasladó voluntariamente a casa de G. A. V., quien tiene con ella una atención especial, de

igual manera que con V.. Manifiesta que conoce que G. A. se ocupa de la alimentación, cuidado, estudio, esparcimiento y todo lo que necesiten J. y V.. Señala que mantiene un vínculo fluido y una excelente relación con su hija, y que le dedica el tiempo que necesita y merece, que cumple con su obligación alimentaria, pero ambos aceptaron la imposibilidad de vivir juntos por el momento.

c) Ordenada la producción de las pruebas ofrecidas por la solicitante las que se incorporan según dan cuenta las constancias de autos. Se acompaña certificados de escolaridad de las adolescentes, certificado de antecedentes de G. V., y recibos de sueldo del Sr. S. cónyuge de G. V.. Con fecha 28/09/2023 el Equipo Técnico de la sede produce informe de Encuesta socio ambiental en domicilio, y Entrevista interdisciplinaria, en la cual las profesionales intervinientes Lic. en Psicología R. T. y Trabajadora Social R. M. V., concluyen: *“...De las intervenciones realizadas se advierte que G. y su grupo familiar se encuentran predispuestos en ser tutores de la crianza de las niñas. Se observa en las entrevistas mantenidas que la Sra. G. V. cuenta con los recursos personales para el cuidado y contención de las niñas que tiene a su cargo, en el relato de las actividades de la vida cotidiana se evidencia un adecuado desempeño en el ejercicio del rol acompañada de otros integrantes del grupo familiar. Se observa registro de las necesidades de las niñas acorde a su etapa evolutiva y una adecuada organización, que han articulado los medios familiares necesarios para favorecer a la satisfacción y contención de las mismas, entendiendo la importancia de la continuidad en sus espacios tanto sean educativos como de otro tipo de actividades. Se observa que ambas tías maternas tienen una fluida comunicación con sus sobrinas, que el vínculo se habría sostenido en el tiempo, que habría participado de la cotidianeidad de las niñas. Las condiciones de vida de los miembros de la familia y la habitabilidad de la vivienda son acordes a los recursos económicos familiares, siendo la responsable la Sra. G. V. junto a la colaboración de su pareja el Sr. S. del cuidado, traslados y salud de las mismas, con la colaboración de la Sra. A. V.. Se advierte en las niñas el establecimiento de un vínculo afectivo y de cuidado con su grupo familiar, siendo contenidas por el mismo, constituyéndose sus tías maternas en referentes emocionales de gran significancia para su desarrollo. Teniendo en cuenta la historia familiar que han atravesado se considera de importancia que las niñas puedan participar de espacios terapéuticos que les permitan tramitar las situaciones familiares vividas...”*.

d) Fijada audiencia a fin de tomar contacto personal con las adolescentes V. V. y J. T. V., la misma tuvo lugar el 27/04/2023, celebrándose con posterioridad, la audiencia con el progenitor de J., C. E. T. y las tías G. A. V. y A. V..

e) Con fecha 28/07/2023 el progenitor de J. V. T., (C. E. T.) ratifica el acta de fecha noviembre de 2022 ante el Juez de Paz de Alto Alegre y la audiencia del 27/04/2023 ante este Tribunal, por la cual cede la guarda provisoria de su hija J. T. V. a sus tías G. y A..

f) Corrida vista de todo lo actuado al Ministerio Complementario, con fecha 01/11/2023, evacua la misma la Asesoría Letrada de 1º Turno, y considera que del análisis de la prueba rendida en autos, le permiten dictaminar de manera favorable a los fines. de que la Sra. G. A. V. sea designada tutora definitiva de V. V. y J. T. V.. Manifiesta que, se torna necesario designar a adultos responsables que ejerzan la representación de las niñas y asuman su crianza, brindándole protección y cuidado, proporcionando un marco legal a una situación que ya se encuentra materializada.

g) Con fecha 21/12/2023 adquiere la mayoría de edad V. V..

h) Dictado el decreto de autos, firme y consentido dicho proveído quedó la presente causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO: **I) Demanda de tutela.** G. A. V. (DNI) y A. V. (DNI) y solicitan se designe a la primera como tutora de sus sobrinas V. V. (DNI), y J. T. V. (DNI).

Manifiestan que las adolescentes están al exclusivo cargo de G. A. V. desde el fallecimiento de sus abuelos (M. I. P., fallecida 04/11/2022 y N. H. V. fallecido el 19/09/2022) quienes fueran designados tutores de V. y ostentaban la delegación de la responsabilidad parental respecto de J. en autos: "P., M. I. Y OTRO – TUTELA" (Nº 8322510), mediante Sentencia nº23 del 09/06/2020.

El progenitor de J. (C. E. T. DNI) presta conformidad a lo peticionado por las solicitantes.

Con fecha 21/12/2023 adquiere la mayoría de edad V. V., por lo que el planeo de tutela respecto de la misma deviene abstracto.

II) Consideraciones preliminares. En la presente causa me encuentro frente a un pedido de tutela aunque sin desplazamiento de la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental que recae sobre el progenitor de la adolescente J..

Así, se avizora a primera vista que pueden converger en el caso traído a decisión principios y axiología de diferentes instituciones: a) la responsabilidad parental (art. 638 y ss CCyC); b) la adopción (art. 594 y ss CCyC); c) la tutela (art. 104 CCyC); d) la

guarda a un pariente (art. 657 CCyC) y; e) la delegación de la responsabilidad parental (art. 643 CCyC).

Ninguna de todas esas instituciones contempla de manera cabal y, específicamente, la situación de J. puesto que: a) el progenitor no es privado (art. 700 CCyC) ni suspendido (art. 702 CCyC) de la responsabilidad parental; b) no se configuran los requisitos para la adopción (art. 597, 607, 611 CCyC); c) existe persona que ejerza la responsabilidad parental -aunque de manera compartida- con los pretensos tutores (art. 104 CCyC); d) se encuentra vencido el plazo de un año que justifica el otorgamiento de la guarda a un pariente (art. 643 CCyC); e) el plazo máximo de un año para el supuesto de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental limita los efectos de la figura al caso de autos (art. 643 CCyC).

Como piedra axial, cabe partir del art. 5 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que dispone: *“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los **derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño** de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”*. Asimismo, el art. 607, último párrafo CCyC señala: *“La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o **referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste**”*.

Preliminarmente señalo que el principio rector en el presente caso se centra en la convergencia de voluntades (progenitor-tutor) que contempla el mejor interés de J. T. V.. Paso revista a las instituciones referidas.

III) Tutela. La tutela es un instituto del derecho de las familias que tiene por finalidad brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental (art. 104 Código Civil y Comercial de la Nación –en adelante CCyC–). En este sentido, se ha sostenido: *“Este sistema de representación es de protección y ha sido instituido en exclusivo beneficio de las personas menores de edad que no estén bajo el régimen de la responsabilidad parental o carezcan de adulto responsable que se haga cargo de su crianza y cuidados necesarios y de su estado de indefensión ya sea por su inmadurez, enfermedad, o características mentales que colocan al niño, niña o adolescente en una particular situación de vulnerabilidad (...)”*

(OLMO, Juan Pablo; IURMAN, Liliana I., *Designación de tutor: aspectos procedimentales*, Publicado en: Sup. Doctrina Judicial Procesal 2015 [octubre], 1, cita online: AR/DOC/2883/2015).

Ante tales circunstancias, el ordenamiento jurídico prevé, de manera subsidiaria, la designación de la representación legal en cabeza de una o más personas (tutores) que acrediten idoneidad suficiente para asumir el cuidado, asistencia y protección del niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad. Se afirma que *“ellos, en tal carácter y como adultos responsables, asumen su crianza, prestándoles educación, asistencia alimentaria, vivienda, salud y esparcimiento. También cuidan de su patrimonio, si lo hubiere, con la debida rendición de cuentas (...) Es esencial a la función del tutor promover la autonomía personal del niño/a y favorecer, en consonancia con sus facultades, la toma de decisiones para sus propios asuntos personales y patrimoniales”* (BALIERO DE BURUNDARENA, Ángeles, *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, Directores: HERRERA, Marisa - CAMELO, Gustavo - PICASSO, Sebastián, Infojus, Buenos Aires, 2015, 1a ed., t. I, p. 220/221).

Asimismo, la tutela y sus disposiciones generales consagran, para una correcta interpretación del instituto, la necesaria aplicación de los principios generales que rigen la responsabilidad parental (enumerados en el art. 639 CCyC): el interés superior del niño/a; la autonomía progresiva del niño/a conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; y el derecho del niño o niña a ser oído y a que su opinión sea tomada en cuenta según su edad y grado de madurez. También se le reconoce su derecho a participar en todos los procesos que le atañen (art. 707 CCyC) (BALIERO DE BURUNDARENA, Ángeles, *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*, Directores: HERRERA, Marisa - CAMELO, Gustavo - PICASSO, Sebastián, Infojus, Buenos Aires, 2015, 1a ed., t. I, p. 220).

La doctrina afirma que *“si bien al delegado (art. 643) (...) se les puede otorgar (...) las capacidades de un tutor, no por ello será propiamente un tutor, y ello es así porque la tutela es una figura definitiva que, para que tenga lugar, exige la privación de la responsabilidad parental de los progenitores, ya que una y otra, (...) no pueden coexistir (...) La tutela pues, como tal, está excluida del art. 104 párr. 3º, del Código. Es que las funciones que se adjudican al delegado o cuidador del niño (...) serán esencialmente transitorias, lo que importa decir que únicamente tendrán validez durante los plazos de vigencia establecidos en los anotados arts. 643 y 657”* (MIZRAHI, Mauricio L., *Cuidado personal de niños por terceros. Exégesis de los*

artículos 104, 643, 657, 674 y 702 del Código Civil y Comercial, La Ley 30/10/2019, 1 La Ley 2019-E, 1145).

A la luz de tales principios, así como de las normas del CCyC que regulan el presente instituto, deberán ser analizados los presupuestos que fundamentan la presente solicitud de designación de tutora de la adolescente J. T. V. a favor de su tía materna G. V..

III.1. Legitimación. Conforme lo dispuesto por el art. 101 inc. b CCyC, corresponde la representación legal de las personas menores de edad no emancipadas, si los progenitores están privados de la responsabilidad parental ó suspendidos en su ejercicio—entre otros supuestos—, al tutor que se les designe. En efecto, tal designación debe ser judicial; el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, y debe fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad (art. 107 CCyC). En este marco normativo, acreditada la situación de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente, se encuentra habilitada a solicitar la tutela de este último toda persona que se considere idónea para el ejercicio de los derechos y deberes inherentes al cargo de que se trata, y que reúna los requisitos (positivos y negativos) exigidos por el CCyC a tal efecto, cuyo cumplimiento será examinado y valorado por el Tribunal conforme la prueba producida en la causa.

Así, pues, la normativa vigente no exige acreditación de vínculo de parentesco alguno entre el pretense tutor respecto del niño, niña o adolescente que carece de progenitores, ni acreditación de inexistencia de otros parientes de grado preferente. Ello así toda vez que, con la entrada en vigencia del nuevo CCyC —a partir del 01/08/2015—, ha quedado derogada la tutela legal (arts. 390 y 392 del Código Civil —ley 340—) y solo existen en la actualidad dos tipos de tutela: la otorgada por los progenitores (art. 106 CCyC) y la tutela dativa (art. 107 CCyC).

III.2. Tutor designado por los progenitores. El art. 106 CCyC dispone que cualquiera de los progenitores que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Por su parte, esta designación debe ser aprobada judicialmente.

Por su parte, la doctrina sostiene que “la designación de tutor/es testamentarios emana de la responsabilidad parental; en virtud de ella, sólo los progenitores están facultados a nombrar persona o personas que, con posterioridad a su fallecimiento, dejan ejercer la tutela de sus hijos menores de edad” (FERNÁNDEZ, Silvia

E., *Comentario al art. 106*, en: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Directores: Marisa Herrera; Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso, Infojus, Bs. As., 2015. T. I, p. 226).

IV) Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. La delegación del ejercicio de la responsabilidad parental no estaba contemplada en la legislación anterior, por entenderse que se encontraba en juego el orden público en el marco del ejercicio de los deberes-derechos de los progenitores y atento a que ese ejercicio constituía el contenido mismo de la responsabilidad parental, no fue prevista la posibilidad de que los padres delegaran en un tercero el ejercicio de sus funciones relativas al hijo menor (HERRERA, Marisa, *Manual de derecho de las familias*, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2015, p. 637).

El CCyC incorpora expresamente la figura de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental a un pariente, por un período de tiempo determinado cuando existan razones suficientemente fundadas y ello redunde en interés del niño, niña o adolescente (en adelante NNA). En el art. 643 CCyC establece: *“En el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 674. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo. Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período más con participación de las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo filial establecido”*.

El art. 643 CCyC brinda respuesta a una significativa cantidad de casos en los que, por distintos motivos (enfermedad, incapacidad sobreviniente, viaje al exterior o a alguna localidad alejada del domicilio familiar o cuestiones de trabajo) los progenitores delegan el cuidado de sus hijos a otra persona (VIDETTA, Carolina A., *La relación entre padres e hijos en el Código Civil y Comercial. Titularidad, ejercicio y cuidado personal: un modelo que consagra la democratización de las relaciones de familia*, RDF 72, 95, AR/DOC/5380/2015).

Así, Nora Lloveras, Olga Orlandi y Gabriel Tavip, al comentar la norma citada, expresan: *“(…) La regulación legal cubre el vacío al reconocer efectos jurídicos a las relaciones entre el niño y los adultos temporalmente responsables de su cuidado, por delegación conjunta de ambos progenitores o de uno de ellos, en su caso. Delegar*

significa dar a otro; otorgar a otra persona el ejercicio de la responsabilidad parental, que les pertenece a los progenitores, para que ese tercero cumpla las funciones respectivas o para conferirle representación. Entre los motivos que pueden autorizar la delegación del ejercicio, puede indicarse la necesidad de permanecer por un período en el exterior o en alguna localidad o región del país lejana al domicilio familia, siendo imposible o dificultoso hacerlo en compañía de su hijo, o cuando el propio niño o adolescente tenga válidas razones para quedarse en el lugar que considera su centro de vida; la existencia de contingencias económicas o sociales que impidan el cuidado personal del hijo; el padecimiento de alguna enfermedad física o mental que temporalmente limite la aptitud del progenitor para hacerse cargo de la crianza del niño, entre otras (...)" (LLOVERAS, Nora; ORLANDI, Olga; TAVIP, Gabriel, *Comentario al art. 643 CCyC*, en: Tratado de derecho de familia según el código civil y comercial de la nación, Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa y Lloveras, Nora (dirs.), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, T. IV, ps. 58 y ss.).

Los requisitos para que opere la delegación del ejercicio son: a) que existan razones suficientemente justificadas; b) que contemple el interés superior del NNA; c) por el plazo de un año, prorrogable por un período más; d) que opere en favor de un pariente; e) que exista un acuerdo de parte de los progenitores; f) que sea homologado judicialmente; g) que el NNA sea escuchado.

Debe quedar claro que los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades, por lo que la delegación recae únicamente sobre el **ejercicio**.

IV.1. La delegación del ejercicio en un pariente. Como puede advertirse de la lectura del art. 643 CCyC, la delegación del ejercicio está prevista únicamente a favor de un pariente, sin que la norma indique qué grado de parentesco, por lo cual puede interpretarse en sentido amplio (todos los parientes como abuelos, tíos, sobrinos, primo segundo) o restringido (sólo aquellos obligados a prestar alimentos, art. 537 CCyC).

V) Otorgamiento de la guarda en un pariente. El Código Civil y Comercial, en el artículo 657, regula la guarda otorgada por el juez a un pariente de la siguiente manera: *"En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual. Vencido el plazo, el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras figuras que se regulan en este Código. El guardador tiene el cuidado*

personal del niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes de esta titularidad y ejercicio”.

Medina entiende a la guarda *"estrechamente identificada con la situación por la cual un niño se encuentra a cargo de otra persona que no son sus progenitores. La noción de guarda integrada a la llamada responsabilidad parental (antes patria potestad), surge como un derecho-deber natural y originario de los progenitores, que consiste en la convivencia con sus hijos y es el presupuesto que posibilita las restantes funciones paternas de educación, asistencia, vigilancia, corrección y representación"* (MEDINA, Graciela, *La guarda directa en el Código Civil y Comercial y en la jurisprudencia de la Corte Suprema*, LA LEY, 06/08/2015, 5).

El otorgamiento de la *guarda* importa, en lo esencial, que el NNA permanezca durante un lapso de tiempo determinado al cuidado de una persona que no sean sus progenitores, y en consecuencia, conlleva el apartamiento del niño o niña de su familia nuclear (progenitores).

Las hipótesis que pueden presentarse para la adopción de esta medida se circunscriben, en general, a la situación de vulneración de los NNA por la permanencia con sus progenitores (peligro o riesgo en la integridad de los NNA) o por el abandono o las dificultades de sus progenitores para hacerse cargo del NNA (LLOVERAS, Nora; ORLANDI, Olga; FARAONI, Fabián, *Comentario al art. 657 del CCyC*, En: Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Directoras: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa; LLOVERAS, Nora, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, T. IV, p. 148).

Se privilegia de esta manera a la familia *extensa* por sobre la nuclear, en razón de constatare circunstancias excepcionales y de gravedad que descarten, temporalmente, la permanencia de los NNA con su grupo familiar más íntimo.

Claro está que la decisión debe asentarse en el interés superior del NNA, esto es, que sea la *más beneficiosa* para éstos. En la opinión consultiva 17/200, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que "...la expresión "interés superior del niño" -art. 3º, Convención sobre los Derechos del Niño- implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida de éste..." (Corte Interamericana de Derechos Humanos - 28/08/2002 - Opinión Consultiva OC- 17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pub. en LA LEY, 2003-F, 108, con nota de Carlos A. Carranza Casares; LA LEY, 2003-B, 313).

VI) El caso de autos. El justo motivo. De un análisis exhaustivo de las instituciones reseñadas precedentemente, considero que *convergen* en la presente causa las figuras de la *tutela* y de la *responsabilidad parental*.

En este escenario, no se me escapa que, como principio general, la tutela es una institución *subsidiaria* del derecho de las familias de naturaleza tuitiva tanto en el aspecto personal como patrimonial, frente a la ausencia de sus progenitores o de quien ejerza su guarda. Es que, por regla general, la figura de la tutela viene a remediar la ausencia de la responsabilidad parental. En este sentido, la Excma. Cámara local afirma que *“el instituto de la tutela se encuentra previsto en la norma sustancial con carácter subsidiario, esto es, para el supuesto que no exista progenitor que pueda ejercer la responsabilidad parental de la que es titular. En otros términos, su aplicación resulta supletoria puesto que rige por falta o imposibilidad de los padres, cuestión que puede suceder por fallecimiento de los progenitores, por declaración de incapacidad o por haber sido privados de la responsabilidad parental o suspendidos en su ejercicio por sentencia firme que así lo disponga (ver Saux, E. Ignacio, en: Lorenzetti, Ricardo Luis, (Director), Código Civil y Comercial Explicado, Parte General, Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, 2021, p. 202)...* El magistrado valoró el fallecimiento de la progenitora Romina Ressia, el antecedente de delegación de la responsabilidad parental efectuada en la causa “T., M. E. C/ R., L. R. - Régimen De Visita/Alimentos – Contencioso”, como también, el conocimiento personal de los niños, las condiciones de idoneidad de la pretensa tutora y la opinión del Ministerio Público Complementario. De ese modo, entendió *“que se encuentra suficientemente fundado y acreditado el motivo que habilita la designación de un tutor para los menores de edad”*. Como se verá, el motivo invocado no resulta suficiente e idóneo, según la ley, para otorgar sin más la tutela. Es que no hubo -como presupuesto ineludible- cese de la responsabilidad parental que corresponde al progenitor de los niños” (Cám. Civ. Com., Flia y Contenciosoadministrativo, Villa M., Sent. N° 61, 15/08/2023, “M., L. M. C/ T., M. E. y otro - Tutela” (Expte. N.º 9489611).

Sin embargo, en este caso concreto, hay una convergencia de voluntades entre todos los *referentes afectivos* de J., donde prima la armonía y la contemplación del mejor interés de la adolescente. En ese tren, el progenitor, sin desprenderse de la responsabilidad parental que detenta y ejerce, considera que su tía materna G. V.

cumple un rol esencial en la vida de su hija, por lo que presta conformidad para que sea designada tutora.

De esta manera, en el caso, no se presenta un *conflicto* entre progenitores y tutores, que los posicione en un binomio antagónico “progenitores-tías” o “responsabilidad parental-tutor”, sino una arquitectura o dinámica familiar construida en beneficio de J., donde todos ellos participan y aportan a su felicidad, sin excluirse.

De allí que, a mi ver, en este escenario y poniendo primero el interés de J., es posible la coexistencia entre la tutela y la responsabilidad parental, ya que, por un lado, no desconozco que *encuadrar* es un gran poder-deber del juez, pero, por otra parte, no debemos *meter el mundo o la vida de J. en conceptos viejos o rígidos*. Es que, el gran desafío es *observar, escuchar y analizar la realidad*, la vida de J., e *integrarla* en esta decisión, más allá de la discusión doctrinaria que trae aparejado el *encuadramiento* en los conceptos jurídicos de tutela o responsabilidad parental. Por ello, las preguntas más relevantes son: ¿Cómo se integra? ¿Cómo contemplo esta realidad? ¿cómo coexisten en esta decisión las instituciones que, en la realidad, se están utilizando por los progenitores y los pretensos tutores?

Desde otro costado se debe valorar también el impacto de la decisión adversa, esto es, el rechazo de la tutela y preguntarse ¿beneficia a alguien? ¿cambia la realidad o la dinámica diaria de J.? ¿el progenitor o la tutora modificarían sus conductas? ¿qué problemas o inconvenientes se presentarían en la vida de J., en la escuela, en el hospital?

Si ninguno de los referentes afectivos de J. se opone a la coexistencia entre la tutela y la responsabilidad parental ¿existe un orden público familiar que deba ser contemplado en esta decisión? ¿a quién protege ese orden público familiar? ¿provocará una desarmonía entre los protagonistas de esta dinámica, inexistente a la fecha?

Tampoco podemos dejar de señalar que no hay otra figura que pueda contemplar adecuadamente esta situación de hecho ya que, por un lado, la delegación de la guarda o delegación de la responsabilidad parental (arts. 643 y 657 CCyC) contemplan períodos de tiempo de un año mientras que esta situación de hecho ya se prolongó a lo largo de varios años de la vida de la adolescente; quien primero estaría al cuidado de sus abuelos y luego de sus tías maternas, ante el fallecimiento primero de su madre y luego de sus abuelos maternos, los cuales detentaban la delegación de la responsabilidad parental respecto de la misma, y para ella todos los vínculos revisten relevancia en su plano afectivo.

Como sostuve, en el presente caso hay una convergencia de voluntades, tanto del progenitor y de las tías de atender de manera prioritaria y preferente el interés superior de la adolescente.

Por un lado, el progenitor reconoce la *necesidad y relevancia* de las funciones que se delegan a los tutores para que puedan *actuar* en la vida cotidiana de la adolescente, en la escuela, en el hospital, en los viajes.

Por lo tanto, el progenitor de J. coexiste desde un lugar de apoyo para la adolescente sin que haya un desplazamiento de los deberes que se les atribuyen respecto del ejercicio de la responsabilidad parental.

Desde otro costado, a nivel sustancial: **a)** en numerosos pasajes del CCyC y también a nivel jurisprudencial, se han reconocido funciones, derechos y obligaciones a los *referentes afectivos* (vgr. progenitor afín, progenitor del corazón); **b)** se ha enaltecido la *autonomía de la voluntad*, al punto que la voluntad procreacional en las TRHA, se consolida como la tercer fuente filiatoria (art. 558 y 562 CCyC); **c)** se reconoce al juez facultades de construir o mantener subsistente vínculos en la adopción, otorgando la adopción plena o simple, pudiendo mantener subsistente el vínculo con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple (art. 621 CCyC). Esto es, una resolución artesanal que se adapte a la realidad concreta de la causa; **d)** el reconocimiento de la triple filiación, de la adopción por integración y de las formas de construir la adopción en base a los vínculos afectivos que existen en relación a los adoptados, permite pensar que el CCyC no regula las instituciones familiares de una manera tajante y excluyente sino que se busca una convergencia y una readecuación fáctica de la realidad a las instituciones jurídicas contempladas en la norma, siempre y cuando las decisiones judiciales se asienten en el prisma axial que es el interés superior de los NNA.

En tal sentido la jurisprudencia expresa: *“La falta de vínculo legal o biológico no resulta óbice para el pedido de tutela efectuado, en tanto cabe reconocer también como pauta para establecer la existencia de un vínculo familiar el “parentesco social afectivo”. Teniendo en cuenta que ya se ha vencido el plazo máximo por el cual el art 657 del Código Civil y Comercial autoriza a otorgar la guarda, en procura de satisfacer el interés superior de la niña, la figura definitiva más idónea para regular la situación de la joven es la de la tutela pues esta figura le va a brindar a la joven la estabilidad necesaria para satisfacer su derecho de crecer en una familia que le brinde cariño, los*

cuidados y asistencia que necesita” (Juz. Flia. Tigre N 1, TIGRE A. T. G. M. s/ Guarda de personas (Art. 234 del CPCC), 14/05/2021).

Teniendo en cuenta esa axiología sustancial mencionada en el párrafo anterior, en este caso me encuentro con *referentes afectivos* (sus tías maternas) que pretenden que se reconozca judicialmente las funciones que fueran delegadas por el progenitor, contando con el consentimiento de este último (*autonomía de la voluntad*), pero sin excluirlo de la responsabilidad parental (*resolución artesanal*).

De allí que, en el caso de autos, todos los participantes se encuentran presentes en la vida de la adolescente J. T. V. constituyendo así referentes afectivos. El afecto como tal o la verdad afectiva que tanta relevancia tiene en la normativa del CCyC también puede servir como norte para establecer una figura jurídica en la que coexistan progenitor y tutora.

Por ello, el estado de hecho de la situación, la voluntad de todos los intervinientes que se expresa libremente en la audiencia que se celebró al efecto, el interés superior de la adolescente, las funciones y la responsabilidad que ejercen tanto el progenitor como la tía materna –pretensa tutora-, me llevan a *aplicar e integrar* en el caso concreto las figuras jurídicas que contemplen todas las aristas involucradas para que todos participen en la vida cotidiana de J..

Como señalé, la presente demanda de designación de tutora, es promovida por G. y A. V. en el carácter de tías maternas de J. T. V.. Las comparecientes solicitan sea designada G. V. tutora de su sobrina, puesto que desde el fallecimiento de sus abuelos en 2022, la adolescente vive en con su tía materna en el domicilio ubicado en el predio desde Villa María tomando ruta R 158 luego desviar hacia Tío Pujio. Que asiste a la Escuela Proa de la ciudad de Villa María.

Por todo lo expuesto, entiendo que se encuentra suficientemente fundado y acreditado el *motivo* que habilita la designación de la compareciente como tutora de su sobrina.

V) Conocimiento personal de J.. En razón de la edad de la adolescente J. T. V. se celebra la audiencia a fin de tomar conocimiento con ella.

El derecho de participación responde al principio constitucional del debido proceso, al que se le suma el principio de inmediatez a partir del contacto materializado en el marco de la audiencia del art. 113 del CCyC. De conformidad con dicha normativa, para el discernimiento de la tutela –y para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad– el juez debe: a) oír previamente al niño, niña o adolescente; b) tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez; c) decidir atendiendo primordialmente a su interés superior. En esa misma línea se dirigen las Reglas de

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, especialmente, la Reglas nº 51 a 78.

Así y siguiendo estos lineamientos, según acta adjuntada con fecha 27/04/2023 se celebró la audiencia mediante la cual tomé conocimiento personal con J. T. V., quien fue acompañada por la pretensa tutora (G. A. V.), su tía (A. V.), su hermana (V. V. quién a la fecha es mayor de edad) y su progenitor (C. E. T.). En el acto estuvo presente el Ministerio Complementario.

VI) Persona propuesta como tutora. Como dije anteriormente, la adolescente no se encuentra ante una situación de vulnerabilidad por ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados. En el presente caso coexisten todos los protagonistas (tía-progenitor) quienes se vinculan de manera armoniosa en miras al mejor interés de la adolescente.

Asimismo, el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente y debe fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad (art. 107 CCyC).

Los elementos aportados al juicio acreditan que la propuesta de su tía, resulta persona idónea como tutora de la adolescente J. T. V., en razón de su solvencia moral y económica, su capacidad para brindarle contención familiar y la atención permanente que le han dispensado.

Ello queda corroborado con la siguiente prueba adjuntada a la demanda: certificado de antecedentes penales de la pretensa tutora; recibos de sueldo de S., R. E. (conviviente de G. V.), quien se desempeña como empleado rural. Además, se destaca la Encuesta socio ambiental en domicilio y Entrevista interdisciplinaria realizadas por el Equipo Técnico de la sede; todo ello valorado conjuntamente con la audiencia de conocimiento personal (27/04/2023) y la documental acompañada.

a) Antecedentes penales. Se incorpora certificado de antecedentes penales respecto de la actora, expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, del que surge que G. A. V. (DNI), no registra antecedentes penales.

De las pruebas aportadas, como así también de la valoración efectuada por el Ministerio Complementario (dictamen de fecha 02/11/2023) –en opinión que comparto–, queda acreditado que la solicitante reúne las condiciones de idoneidad moral exigidas por ley y no se encuentra dentro de las personas excluidas para ser tutores (art. 110 incs. e y f en sentido contrario CCyC).

b) La escolaridad de J. T. V. se encuentra acreditada con el certificado expedido por la **ProA Escuela Experimental con Énfasis en TIC – Sede Villa María – Desarrollo de Software.**

c) La Encuesta socio ambiental e informe interdisciplinario efectuado por el Equipo Técnico de la sede refiere que desde septiembre de 2022 J. convive con su hermana V. en la casa de su tía G. y su pareja R. E. S. y los hijos de ellos M. y B. S. (primos). Por otro lado, consta que J. frecuenta a su progenitor esporádicamente, pero en oportunidades se habría dificultado sostener el vínculo y que su tía A. V.: “...Se encuentra dispuesta a colaborar con su hermana en la crianza de sus sobrinas, con quienes se relaciona durante los fines de semana por cuestiones de distancia geográfica y organización familiar...”.

Así también se destaca: “...**Aspecto laboral y económico:** La Sra. V. es ama de casa y su pareja el Sr. S. es empleado rural/mixero, durante todos estos años se acompañaron en las tareas cotidianas de mantenimiento del campo. Recibe el alquiler de unos campos familiares que se dividen desde que falleció su hermana, las niñas tienen disponible la suma de dinero de \$250000 para gastos diarios, indica además que su pareja tendría un ingreso que es de aproximadamente \$400000 por lo que cubrir las necesidades de las niñas no sería una dificultad. Manifiesta que en la vivienda no pagan los servicios, desde que se encuentran habitando la casa acordaron ese arreglo con el empleador, puntualiza que tienen quintas y acceden a carne para la alimentación diaria de todos los miembros de la familia.

Aspecto sanitario: La Sra. V. y su grupo familiar no presentarían problemas de salud crónicos ni enfermedades, por lo que las atenciones médicas son las de rutina, en relación a sus sobrinas gozan de buena salud. J. se encuentra asistiendo desde principios del corriente año a espacio de psicología con la Lic. L. Z. con frecuencia quincenal.

Conclusiones: ...Se observa en las entrevistas mantenidas que la Sra. G. V. cuenta con los recursos personales para el cuidado y contención de las niñas que tiene a su cargo, en el relato de las actividades de la vida cotidiana se evidencia un adecuado desempeño en el ejercicio del rol acompañada de otros integrantes del grupo familiar. Se observa registro de las necesidades de las niñas acorde a su etapa evolutiva y una adecuada organización, que han articulado los medios familiares necesarios para favorecer a la satisfacción y contención de las mismas, entendiendo la importancia de la continuidad en sus espacios tanto sean educativos como de otro tipo de actividades. Se observa que ambas tías maternas tiene una fluida comunicación con sus sobrinas,

que el vínculo se habría sostenido en el tiempo, que habría participado de la cotidianidad de las niñas. Las condiciones de vida de los miembros de la familia y la habitabilidad de la vivienda son acordes a los recursos económicos familiares, siendo la responsable la Sra. G. V. junto a la colaboración de su pareja el Sr. S. del cuidado, traslados y salud de las mismas, con la colaboración de la Sra. A. V.. Se advierte en las niñas el establecimiento de un vínculo afectivo y de cuidado con su grupo familiar, siendo contenidas por el mismo, constituyéndose sus tías maternas en referentes emocionales de gran significancia para su desarrollo. Teniendo en cuenta la historia familiar que han atravesado se considera de importancia que las niñas puedan participar de espacios terapéuticos que les permitan tramitar las situaciones familiares vividas...”.

VIII) Consideraciones especiales.

a) Opinión de J. T. V.. El derecho a participar en el proceso judicial (art. 707 CCyC) no solo comprende la asistencia a la entrevista personal (art. 113 CCyC), sino que la opinión por la adolescente vertida sea tenida especialmente en cuenta para la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que le atañen puesto que, de esta manera, se garantiza su efectiva y concreta participación.

De la entrevista surge la contención brindada por su tía G., que vive con ellos y se ha integrado con el resto del grupo familiar, con quienes realizan distintas actividades de recreación y esparcimiento. Que comprende el rol de cada uno, siendo sus tías quienes le brindan cuidado, cariño, pero también no deja de lado el vínculo que mantiene con su progenitor.

b) Opinión del Ministerio Público Complementario. El Asesor Letrado de Primer Turno, Diego Julián, representante del Ministerio Complementario, en oportunidad de contestar la vista de todo lo actuado, presta conformidad a la designación de G. A. V. como tutor de su representada: “... *En suma, del análisis de la prueba rendida en autos, permiten al suscripto dictaminar de manera favorable a los fines. de que la Sra. G. A. V. sea designada tutora definitiva de V. V. y J. T. V.. En el caso de marras, se torna necesario designar a adultos responsables que ejerzan la representación de las niñas y asuman su crianza, brindándole protección y cuidado, proporcionando un marco legal a una situación que ya se encuentra materializada...*”.

IX) Conclusión. El Tribunal nada tiene para observar respecto del trámite cumplido en el juicio y coincide con la opinión expuesta precedentemente por el Asesor Letrado de Primer Turno, Diego Julian, en el carácter de representante del Ministerio Público Complementario.

En el caso de autos, debo contemplar especialmente la situación en la que se encuentra la adolescente que posee un vínculo con su progenitor y con sus tías, por lo tanto, sin desconocer la finalidad tuitiva y subsidiaria del instituto de la tutela, es la que mejor resguarda el interés superior de J. T. V., consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño en sus arts. 1, 3 y 9 inc. 1 y 3, norma internacional que integra la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) y ley 23849.

Se trata, en definitiva, de efectuar un abordaje asentado en la realidad y con cierto margen de flexibilidad a fin de *aggiornar* los efectos de la tutela al mejor interés de la adolescente, ponderando los antecedentes familiares, históricos, referentes afectivos, en fin, todos los vínculos y afectos en juego. Es una **labor artesanal** que debe afrontarse con responsabilidad.

Por todo lo expresado, considero que la designación de G. A. V. DNI como tutora de su sobrina J. T. V. resulta beneficiosa para la adolescente, toda vez que ella constituye y desempeña un verdadero referente afectivo y forman parte de su centro de vida, sin desconocer el rol trascendental y la contención brindada por el resto de su grupo familiar.

En consecuencia, corresponde designar tutora a la solicitante, a fin de brindarles a J. T. V. un marco conveniente para asegurar su desarrollo integral en el plano espiritual, material y afectivo, sin desconocer la vinculación con su progenitor.

X) Coexistencia entre responsabilidad parental y tutela. Como sostuve la delegación de la guarda o del ejercicio de la responsabilidad parental (arts. 643 y 657 CCyC) contemplan períodos de tiempo de un año mientras que esta situación de hecho ya se prolongó a lo largo de muchos años de la vida de la adolescente (primero con sus abuelos y luego con su tía) y para ella todos los vínculos revisten relevancia en su plano afectivo.

Por ello, corresponde *integrar* las figuras de la responsabilidad parental con la tutela que se declara en esta resolución.

Los tutores y los progenitores deberán coordinar las funciones y adoptar decisiones más relevantes en beneficio de J. (arg. art. 641 y 645 CCyC) y, por su parte, podrán ejercer indistintamente los deberes y facultades referidas a la vida cotidiana de la adolescente (arg. art. 648 CCyC).

En caso de desacuerdo entre progenitores y tutores, se resolverá judicialmente, previa audiencia con todos ellos y con la intervención del Ministerio Complementario (arg. art. 642 y 656 CCyC).

XI) Costas del juicio. Las costas del juicio se distribuirán por el orden causado por los siguientes fundamentos.

a) si bien muchas veces se observa que las costas se suelen imponer a los niños o adolescentes respecto de los cuales se declara la tutela, con el fundamento de que el proceso se promovió en protección de sus intereses, tal interpretación no puede sostenerse en este caso.

b) por un lado, los pretensos tutores requieren que se les reconozca las funciones que ejercen y que han sido delegadas por los progenitores.

c) por otro lado, los progenitores buscan plasmar en una resolución judicial la realidad de la niña en el día a día, sin desatenderse de la responsabilidad parental que les cabe.

d) como dije antes, hay una confluencia de voluntades, sin oposición, sin contradictorio que busca transparentar la realidad de la niña.

e) así, resulta justo que todos los adultos involucrados (progenitores y tutores) afronten los costos del proceso, en lo que a su intervención respecta.

XII) Honorarios. Señala la doctrina que “el proceso de nombramiento o remoción de tutor o curador carece de contenido económico propio” (MENTA, Marcela A., *Costas y honorarios en los procesos de tutela y curatela*, en: *Costas y honorarios en los procesos de familia*, Director: Sebastián Monjo, Toledo, Córdoba, 2022, p. 869).

Atento lo dispuesto por los arts. 26 y 80 de la Ley 9459, estimo justo y equitativo establecer los honorarios de la Dra. S. R. T., en el equivalente a treinta (30) Jus por su labor desarrollada en el presente juicio de nombramiento de tutores, esto es, la suma de pesos quinientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y seis (\$582.156), conforme pautas cualitativas del art. 39 Ley 9459. También corresponde regular honorarios por tareas previas y apertura de carpeta conforme lo dispone el art. 104 inc. 5 ley 9459, en la suma de \$58.215,60.

Por lo expuesto, normas legales citadas, los arts. 101 inc. b, 107, 110 en sentido contrario, 113, 643 y ctes. del CCyC; arts. 892 inc. 2, correlativos y concordantes del CPCC, lo dictaminado por el Ministerio Público Complementario y demás normas legales citadas;

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda promovida y, en consecuencia, designar tutora de la adolescente **J. T. V. (DNI)**, a su tía G. A. V. (DNI), con domicilio real en el predio desde Villa María tomando ruta R 158 luego desviar hacia Tío Pujio, Provincia de Córdoba, quienes deberán aceptar el cargo en forma.

II) Comunicar a G. A. V. que deberán velar por su salud y su cuidado, con la obligación de asistirla convenientemente en todas las necesidades físicas morales e intelectuales, y con la facultad de tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana.

III) Disponer que la designación de tutores no impacta en la responsabilidad parental que recae sobre su progenitor C. E. T. (DNI).

IV) Integrar las figuras de la responsabilidad parental con la tutela que se declara en esta resolución.

IV.1. La tutora y el progenitor deberán coordinar las funciones y adoptar decisiones más relevantes en beneficio de J. (arg. art. 641 y 645 CCyC) y, por su parte, podrán ejercer indistintamente los deberes y facultades referidas a la vida cotidiana de la adolescente (arg. art. 648 CCyC).

IV.2. En caso de desacuerdo entre progenitores y tutores, se resolverá judicialmente, previa audiencia con todos ellos y con la intervención del Ministerio Complementario (arg. art. 642 y 656 CCyC)

V) Disponer la toma de razón del presente pronunciamiento en el acta de nacimiento respectiva (acta n°, Tomo, año), a cuyo fin ofíciase al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Alto Alegre, Provincia de Córdoba.

VI) Se dispone el ejercicio cooperativo del rol de cuidado por tía materna A. V. DNI.

VII) Imponer las costas del juicio de tutela por el orden causado, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. S.R. T., en la suma de pesos quinientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y seis (\$582.156), con más la suma de pesos cincuenta y ocho mil doscientos quince con sesenta centavos (\$58.215,60) correspondientes a apertura de carpeta y tareas previas.

PROTOCOLÍCESE, AGRÉGUESE COPIA AL EXPEDIENTE Y NOTIFÍQUESE A LA PARTES, A LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS.-

FDO.: MONJO, Sebastián.